

第3節 不能犯

刑法
No.140

予備独自問題 H30-8

(配点: 3)

月 日
月 日

不能犯と未遂犯を区別する基準についての次の【見解】に関する後記1から5までの各【記述】を検討し、正しいものを2個選びなさい。

【見 解】

行為当時一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を基礎とし、一般人を基準に結果発生の危険性があるか否かの判断による。

【記 述】

1. この【見解】によれば、人を殺そうとして、客観的には死の結果を引き起こさない量の空気を人の血管内に注射した場合、殺人未遂罪の成立が認められる余地がある。
2. この【見解】によれば、結果発生の危険性の有無は、実際に存在した事実のほかどのような事実が存在すれば結果が発生し得たかを事後的見地から検討し、そのような事実が行為時に存在し得る可能性の程度を考慮して判断することになる。
3. この【見解】によれば、人を殺そうとして、一般人ならば明らかに砂糖と分かる黒糖を毒薬と思い込んで紅茶に入れて飲ませた場合、この行為者の認識した事情を基礎として、一般人を基準に、この行為による死の結果発生の危険性の有無を判断することになる。
4. この【見解】によれば、行為者が特に認識した事情も基礎とされるので、結果を引き起こす特別な事情を認識している行為者による行為には結果発生の危険性が認められ、その事情を認識していない行為者による行為には結果発生の危険性が認められない場合がある。
5. この【見解】によれば、結果が発生しなかった原因が科学的に説明できる場合には、常に結果発生の危険性は否定されることになる。

No140	不能犯と未遂犯の区別	正答率
予備H30-8	正解 1、4 (順不同)	64%

不能犯の成否を決する本記述の【見解】は、行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を基礎とし、一般人を基準に結果発生危険性があるか否かの判断によるとする、具体的危険説と呼ばれる立場である。

他にも、事後的な視点を入れて、結果惹起の可能性・蓋然性をより客観的に判断する客観的危険説と呼ばれる立場も存在する。

1 正しい

本記述において、一般人が認識した事情は、空気を人の血管内に注射する行為である。同行為は、被注射者の身体的条件その他の事情によっては死の結果発生危険が絶対にはないとはいえない。また、行為者は人を殺そうとしており、客観的には死の結果を引き起こさないことを特に認識していたとはいえない。よって、客観的には死の結果を引き起こさない量の空気を人の血管内に注射することは、一般人を基準に結果発生危険性があり、殺人未遂罪の成立が認められる余地があるといえる。なお、判例(最判昭37.3.23、百選I66事件、不能犯)は、本記述と類似の事案において、「空気の量が致死量以下であっても被注射者の身体的条件その他の事情の如何によつては死の危険が絶対にはないとはいえない」とする原審認定を維持して、殺人未遂の成立を肯定している。

2 誤っている

本記述は、具体的危険説を採る【見解】とは異なり、客観的危険説について述べている点で、誤っている。

【見解】は、行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を基礎とし、一般人を基準に結果発生危険性があるか否かの判断によるとする、具体的危険説と呼ばれる立場である。他方で、本記述は、結果発生危険性の有無について、実際に存在した事実のほかによどのような事実が存在すれば結果が発生し得たかという事後的な視点を入れて、そのような事実が行為時に存在し得る可能性の程度を考慮しているので、客観的危険性と呼ばれる立場について述べている。

3 誤っている

本記述は、行為者の認識した事情のみを基礎としている点、及び、一般人ならば明らかに砂糖と分かる黒糖を毒薬と思い込んだ事情を、行為者の認識した事情として判断の基礎としている点で、誤っている。

【見解】によれば、行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を基礎として、一般人を基準に結果発生危険性があるか否かを判断する。よって、行為者が特に認識した事情だけでなく、行為時に一般人が認識し得た事情も基礎としなければならない。また、具体的危険説が判断の基礎に行為者が特に認識していた事実を取り込んでいるのは、一般人には認識し得ない事実を行為者が積極的に利用した場合、例えば、一般人には砂糖にしに見える粉末を行為者が胃酸カカリであることを知って人に飲ませた場合に不能犯としてしまうのは妥当ではないと考えられているためである。そうすると、本記述において、行為者が毒薬と思い込んでいたとしても、一般人が、明らかに砂糖とわかる以上、行為者の認識した事情を基礎として死の結果発生危険性の有無を判断することはできない。

4 正しい

【見解】によれば、行為当時一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を判断基底として不能犯か否かが判断される。【見解】によると、行為者が特に予見した事情の有無により判断基底が異なるといえ、結果を引き起こす特別な事情を認識している行為者による行為には結果発生の危険性が認められ、その事情を認識していない行為者による行為には結果発生の危険性が認められない場合があるといえる。よって、本記述では、行為者が特に認識した事情も基礎とされるので、結果を引き起こす特別な事情を認識している行為者による行為には結果発生の危険性が認められ、その事情を認識していない行為者による行為には結果発生の危険性が認められない場合があるといえる。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

本記述は、【見解】によれば、結果が発生しなかった原因が科学的に説明できる場合には、常に結果発生の危険性は否定されることになるとしている点で、誤っている。

【見解】によると、行為当時一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を判断基底として、一般人を基準に不能犯か否かが判断される。そうすると、事後的に結果が発生しなかった原因が科学的に説明されたとしても、結果発生の危険性が否定されることにはならない。よって、

【見解】では、結果が発生しなかった原因が科学的に説明できる場合には、常に結果発生の危険性が否定されることにはないといえない。

以上により、正しい記述は1と4であり、したがって、正解は肢1と肢4（順不同）となる。